

1500649-14.2022.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCOS AUGUSTO BARBOSA DOS REIS

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/11/2022

... contundentes e indicam a prática de tráfico ilícito de entorpecentes pelo acusado.

Os Policiais apresentaram depoimentos seguros e sólidos sobre a diligência que culminou com a abordagem e prisão do acusado em local onde há grande incidência de tráfico de drogas nesta cidade de Jacareí. Os milicianos relataram que realizavam em patrulhamento pelo local dos fatos, quando ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

1ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/n, Jacareí-SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500649-14.2022.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500649-14.2022.8.26.0617

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2131509/2022 - DEL.SEC.JACAREI

PLANTÃO, 24971859 - DEL.SEC.JACAREI PLANTÃO, 2131509 - DISE- DEL.SEC.JACAREI, 2131509/2022 - DISE- DEL.SEC.JACAREI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARLON GUILHERMO DIACOMO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCOS AUGUSTO BARBOSA DOS REIS

Vistos.

1.MARLON GUILHERMO DIACOMO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no crime descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, no dia 13 de maio de 2022, por volta das 21h30min, na Estrada Lagoa Azul, bairro Lagoa Azul, nesta cidade e comarca de Jacareí/SP, o acusado, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, trazia consigo,

guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico ilícito, as seguintes drogas: 129 porções (sendo 09 de "Skank" e 19 de "K2" - maconha sintética) de Cannabis Sativa L, com peso líquido de 260,26g, 119 porções de cocaína, com peso líquido de 75,7g e 97 porções de cocaína na forma vulgarmente conhecida como crack, com peso líquido de 29,42g.

A denúncia foi oferecida em 14 de junho de 2022 (fls. 84/86).

Após a apresentação de defesa preliminar (fls. 125/128) a denúncia foi recebida no dia 08 de setembro de 2022 (fls. 137/141).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas. Ao final, o réu foi interrogado.

Em debates, o Dr. Promotor de Justiça, após análise da prova produzida, postulou a condenação do réu por entender que restou demonstrada a acusação descrita na denúncia. A Douta Defesa, por seu turno, pugnou pela absolvição do réu por insuficiência de provas, na forma do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, no caso de condenação, requereu a aplicação da causa de redução de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos e a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, facultando ao réu a possibilidade de interposição de recuso em liberdade.

É o relatório.
Fundamento e decido.

2.A ação penal é procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva está substanciada pelo Auto de Prisão Em Flagrante (fls. 01/08), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 14/15), Laudo de Constatação Prévia de Substância Tóxica (fls. 17/24), Boletim de Ocorrência (fls. 38/41), Laudo de Objetos (fls. 69/73), bem como pelo Laudo de Exame Químico Toxicológico de fls. 74/78, que constatou tratar-se, efetivamente, de substâncias entorpecentes (maconha e cocaína).

A autoria restou igualmente comprovada.

O réu MARLON GUILHERME DIACOMO, interrogado em solo policial, negou o tráfico de drogas. Estava na posse de um tucho de maconha e um tucho de cocaína quando foi abordado por policiais militares. Desconhece a procedência do restante das drogas. É peruano e está residindo no Brasil desde 2013. Em juízo, ao ser interrogado, o réu voltou a negar o crime, aduzindo que estava voltando para casa. Os policiais queriam saber quem era o traficante de drogas do bairro e disse a eles que não sabia. Também aduziu aos policiais que reside sozinho nesta cidade. O flagrante teria sido forjado pelos policiais. Nunca teve qualquer passagem criminal no seu país e no Brasil. Não conhecia os policiais que atuaram na ocorrência. É usuário de maconha e cocaína. Reside no Brasil há 09 anos, inicialmente na Zona Leste, na cidade de São Paulo e, depois, em Jacareí. Residiu por fim no bairro Lagoa Azul em Jacareí. Trabalha com construção civil. Não tem filhos. É solteiro. Só tem um tio que mora no Brasil na cidade de São Paulo, mas não tem contato com ele.

Na espécie, a negativa do réu ficou isolada nos autos ao ser confrontada com as demais provas produzidas durante a regular instrução do feito.

A testemunha ELTON ARLINDO FEITOSA DA SILVA, Policial Militar declarou que na data dos fatos encontrava-se de serviço com a VTR.I-41.218, quando pela Praça da Lagoa Azul, avistaram um indivíduo que ao perceber a presença da viatura tentou se

evadir, mas foi abordado. Em busca pessoal foi encontrado oculto em sua pochete, 09 saches de skank, 09 potes de K2 (maconha sintética), 17 saches de maconha, 09 tiras de maconha, 43 Pinos contendo cocaína, 06 saches contendo cocaína, 15 porções de Crack atadas em embalagem plástica, 32 recipientes plásticos contendo cocaína na forma de "crack", 50 Pinos contendo cocaína na forma de "crack", bem como a quantidade em espécie de RS 362,00. Ato contínuo, o indivíduo foi identificado como sendo o acusado Marlon Guilherme Diacomio, que não portava documentos, alegando ser peruano. O acusado indicou onde estariam ocultas as demais substâncias entorpecentes, imaginando que seria liberado, tendo apontado um local próximo escondido atrás de um cercado, onde foi encontrada a quantia de 10 potes de K2, 25 tiras de maconha, 50 saches de maconha, 70 Pinos de cocaína, que estavam em outra pochete. O acusado foi preso em flagrante e conduzido ao Distrito Policial. Em juízo, apresentou basicamente o mesmo relato, aduzindo que o local da ocorrência é conhecido por ser ponto de venda de drogas. Não conhecia o acusado. O acusado declarou que estava morando na região do bairro Lagoa Azul, onde há uma área invadida, e se encontrava desempregado. Por isso estava realizando o tráfico de drogas. Além das drogas tradicionais encontraram com o réu drogas especiais que dificilmente são encontradas (K2 e Skank). Não havia denúncia anônima indicando que um indivíduo de origem estrangeira estaria traficando drogas no local. Havia outras pessoas transitando pelas imediações, mas apenas o réu correu. O restante das drogas foi encontrado perto do ponto inicial de abordagem do acusado. Não presenciaram nenhum ato de venda de drogas. O acusado não forneceu maiores detalhes sobre a sua vida pessoal, especificamente a quanto tempo estava no país.

No mesmo sentido o depoimento do policial militar IRACITAN MOREIRA COIMBRA NETO, que participou da prisão em flagrante do réu.

Pois bem.

As provas produzidas são contundentes e indicam a prática de tráfico ilícito de entorpecentes pelo acusado.

Os Policiais apresentaram depoimentos seguros e sólidos sobre a diligência que culminou com a abordagem e prisão do acusado em local onde há grande incidência de tráfico de drogas nesta cidade de Jacareí. Os milicianos relataram que realizavam em patrulhamento pelo local dos fatos, quando avistaram o acusado, que tentou empreender fuga ao perceber a presença da viatura policial, mas acabou sendo detido, trazendo consigo substancial quantidade de drogas em uma pochete (09 saches de skank, 09 potes de K2 (maconha sintética), 17 saches de maconha, 09 tiras de maconha, 43 Pinos contendo cocaína, 06 saches contendo cocaína, 15 porções de Crack atadas em embalagem plástica, 32 recipientes plásticos contendo "crack", 50 Pinos contendo "crack", bem como a quantia em espécie de RS 362,00, certamente proveniente da venda de drogas que desenvolvia no local.

Informalmente o acusado declarou que estava realizando a venda de drogas por estar desempregado e residia em uma área do bairro Lagoa Azul onde existe uma ocupação irregular.

Aqui neste ponto o crime de tráfico de drogas já estava devidamente caracterizado.

Afasto, contudo, qualquer relação do réu com as drogas apreendidas em um segundo momento pela polícia por entender pouco crível o relato dos milicianos no sentido de que o réu, já detido na posse de substancial quantidade de drogas, indicasse outro local totalmente diverso e que jamais seria encontrado pelos mesmos policiais, onde estaria ocultando outras drogas.

Aqui é importante salientar que o réu já trazia consigo elevada quantidade de drogas e certamente não precisava ocultar outras drogas também em quantidade substancial em

local próximo.

Logo, por entender não haver prova objetiva indicando a relação do réu com a droga encontrada pela polícia após a sua abordagem, o tráfico de drogas está comprovado, mas a análise das circunstâncias objetivas e subjetivas do caso está limitada ao que foi apreendido com o réu no ato da abordagem.

Por fim, os Policiais Militares são funcionários públicos e seus depoimentos não podem ser taxados, a princípio como suspeitos sem comprovação de qualquer intenção dos mesmos em prejudicar o réu, que é estrangeiro (peruano) e nem conhecia os policiais que atuaram neste caso, caindo por terra a alegação de “flagrante forjado”.

Nesse sentido: “Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente desprezado, máxime quanto estas se harmonizam com os demais elementos colhidos no processo e nada indique que tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes” (TACRIM-SP, Rel. Gonzaga Franceschini – RJD 18/80).

“Sem o menor cabimento desmerecer a prova testemunhal, com o argumento genérico de que se cuidou de depoimento de policiais. O policial é agente do Estado e exerce função pública, dedicada exatamente à prevenção e à repressão do crime, em suas várias modalidades. Desmerecer seus testemunhos apenas pela natureza da função que exerce, a par de não ter suporte em qualquer preceito legal, implicaria num imposto preconceituoso e desarrazoado atestado de inidoneidade de toda uma corporação” (TJSP – AP – 1ª C. – Rel. Marcial Holanda – j. 10.04.95 – RT 721/414). (in Código de Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Alberto Silva Franco, Rui Stoco e outros, editora RT, 1999, volume 2, págs. 1833/1835).

O réu deverá responder pelo tipo penal do artigo 33, da Lei 11343/06.

3. Passo à dosimetria da pena, na forma do artigo 68, do Código Penal.

Sopesadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, tendo em vista o disposto no artigo 42, da Lei 11.343/06, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, com valor fixado no mínimo.

Anoto, nesta oportunidade, que a quantidade de droga não foi substancial a ensejar a majoração da pena na primeira fase e as drogas do tipo Skank ou K2 nada mais são, como bem salientou a Defensoria Pública, um tipo de maconha mais pura, que ainda é bem menos danosa do que a cocaína e o “crack”.

Na segunda fase não há circunstâncias agravantes e/ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, a despeito da manifestação contrária do Parquet, entendo que o réu faz jus ao benefício do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. Aliás, ele faria jus até mesmo ao Acordo de Não Persecução Penal que não foi oportunizado no momento adequado.

O réu é primário e está residindo no Brasil desde o ano de 2013, não havendo contra ele qualquer imputação penal neste período, nem muito menos notícias de abordagens. Não havia denúncia anônima noticiando traficância habitual desenvolvida por ele na comunidade onde reside. E a quantidade de drogas encontrada com ele não foi substancial a ponto de vedar o benefício, sendo importante ressaltar que as nossas Cortes Superiores têm admitido o benefício em questão para casos em que há apreensão de muito mais quantidade de droga. A quantidade de drogas por si só também não pode vedar o benefício, mormente porque não há qualquer investigação desenvolvida demonstrando que o acusado realizava esta atividade ilícita como meio de vida ou que estaria inserido em uma organização criminosa.

Ao que parece o acusado passou a vender drogas em razão do seu desemprego. Apesar

da gravidade da imputação entendendo que ele pode ter uma nova chance para retomar a sua vida em sociedade, e aguardar eventual procedimento administrativo do Ministério da Justiça para deliberar sobre a sua permanência ou não no território nacional.

Assim, reduzo a reprimenda estabelecida, com fulcro no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, em metade, resultando em 02 anos e 06 meses de reclusão, além de 250 dias-multa.

Especificamente sobre o benefício acima referido este Magistrado adota o entendimento no sentido de que a redução da pena deve ficar ao arbítrio do Juiz, que deverá levar em consideração o artigo 59, do Código Penal e, também, o artigo 42, da Lei 11343/06. Evidentemente que a redução no patamar máximo não é obrigatória pela própria redação do dispositivo legal em testilha (artigo 33, § 4º, da Lei 11343/06 - "As penas poderão ser reduzidas..."), principalmente por não se tratar de direito subjetivo do réu. Nesse sentido, aliás, decidiu recentemente o Tribunal de Justiça de São Paulo, que considerou justa a redução intermediária, nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11343/06 para caso semelhante: "... Artigo 33, § 4º, da Lei 11343/06. Redução Máxima. Impossibilidade. Expressiva quantidade de droga apreendida (36 porções contendo cocaína). Concessão do benefício depende do livre arbítrio do Juiz que tem de levar em consideração o artigo 59, caput, do Código Penal, e também o artigo 42, da Lei 11343/06. Recurso desprovido" (Apelação Criminal nº 990.10.175503-3, Itaquaquecetuba, 6ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Machado de Andrade, j. 26 de Agosto de 2010).

No caso concreto, o réu foi surpreendido pela polícia na posse de substancial quantidade e diversidade de drogas, duas delas bastante raras, nos termos acima expostos. Mas, por outro lado, ele é primário, e não ostenta qualquer envolvimento criminal no Brasil desde a sua chegada no ano de 2013, motivo pelo qual entende este Magistrado que está justificada a redução da pena no patamar intermediário estabelecido, tomando-se por base o artigo 59, do Código Penal e o artigo 42, da Lei 11343/06.

E o Superior Tribunal de Justiça enfrentou a questão e confirmou sentença judicial que aplicou a fração mínima redutora para o crime de tráfico de entorpecentes em caso semelhante a este tratado nestes autos. Confira-se a propósito: "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FRAÇÃO DO REDUTOR. DISCRICIONARIEDADE. QUANTIDADE DE DROGA. REDUÇÃO NO MÍNIMO LEGAL JUSTIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE. 1. Tendo o legislador previsto apenas os pressupostos para a incidência do benefício legal, deixando, contudo, de estabelecer os parâmetros para a escolha entre a menor e a maior frações indicadas para a mitigação pela incidência do § 4º do art. 33 da nova Lei de Drogas, devem ser consideradas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, e, com preponderância, a natureza e a quantidade da droga, a personalidade e a conduta social do agente. 2. Não há ilegalidade na aplicação do redutor no percentual de 1/6 (um sexto), de acordo com o previsto nos arts. 42 da Lei 11.343/06 e 59 do CP, dada a considerável quantidade de substância entorpecente - 103 gramas de cocaína, 37 gramas de crack e 560 gramas de maconha - apreendida com o paciente. APLICAÇÃO DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO PELA CORTE ORIGINÁRIA EM SEDE DE APELAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS CONFIGURADA. OFENSA AO ART. 617 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. 1. Constatado que o Tribunal, julgando apelo exclusivo da defesa, findou por não aplicar a causa especial de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, expressamente reconhecida na sentença em favor do paciente, resta evidenciada a reforma a pior nesse ponto, em nítida ofensa ao art. 617 do CPP, que proíbe a reformatio in pejus, constrangimento sanável de ofício através da via eleita. REGIME PRISIONAL. COMETIMENTO NA VIGÊNCIA DA LEI 11.464/07. MODO FECHADO. IMPOSIÇÃO LEGAL. COAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. 1. A Lei 11.464/2007, introduzindo nova redação ao art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90,

estabeleceu o regime inicial fechado para o resgate da reprimenda firmada em relação aos delitos hediondos, cometidos após a sua entrada em vigor. 2. Ordem denegada, concedendo-se, contudo, habeas corpus de ofício para fixar a pena do paciente definitivamente em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa" (STJ, HC 202758 / SP, Relator Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 07.02.2012).

Não há causas de aumento de pena.

Finalizando, tendo em vista as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria, bem como o conteúdo da Resolução 05/12, do Senado Federal, que suspendeu dispositivo legal da lei de drogas que proibia a substituição da pena privativa de liberdade, o acusado preenche os pressupostos legais do artigo 44, do Código Penal, tomando-se por base as circunstâncias do crime e a personalidade do agente, que é tecnicamente primário.

Portanto a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos é suficiente para prevenção e repressão do crime praticado.

Assim, substituo a pena privativa de liberdade fixada, na forma do artigo 44, do Código Penal, por duas penas restritivas de direitos, sendo uma de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena privativa de liberdade aplicada, e outra de prestação pecuniária, consistente no pagamento da quantia equivalente a 01 salário mínimo, que será destinado a uma instituição carente devidamente cadastrada perante este juízo.

Finalizando, no caso de descumprimento do benefício acima concedido estabeleço o regime inicial aberto para cumprimento da pena, tendo em vista a pena total cominada, o período de custódia cautelar, bem como a recente decisão do Supremo Tribunal Federal que afastou a natureza hedionda para o caso de tráfico de drogas privilegiado.

4. Posto isso e considerando o que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de condenar o réu MARLON GUILHERMO DIACOMO, a cumprir pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída na forma do artigo 44, do Código Penal, nos termos acima expostos, e ao pagamento de 166 dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Determino, ainda, o confisco dos bens apreendidos, de origem ilícita, nos termos do artigo 243, § único, da Constituição Federal de 1988.

Outrossim, diante do conteúdo desta sentença não subsistem os requisitos autorizadores da prisão cautelar, razão pela qual concedo ao réu o benefício da liberdade provisória mediante cumprimento de todos os requisitos de praxe, e entrega em cartório, no prazo de 48 horas, do seu passaporte peruano, que ficará apreendido até o término do cumprimento de sua pena.

Expeça-se, portanto, alvará de soltura clausulado em favor do réu.

Determino, por fim, a expedição de ofícios: a) à Polícia Federal comunicando que o réu está proibido de deixar o país em razão de cumprimento de pena por crime de tráfico de drogas; b) ao Ministério da Justiça após o trânsito em julgado desta sentença condenatória por crime de tráfico de drogas cometido por pessoa de nacionalidade estrangeira em território nacional para eventual instauração de procedimento administrativo para expulsão do condenado do Brasil, na esteira dos artigos 65 e 71, da Lei 6815/80, instruindo esse ofício com cópias das principais peças deste processo.

Com o trânsito em julgado expeça-se o necessário para início da fase executória.

Jacarei, 10 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA